

1501116-27.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/06/2022

... no ano de 2016 por crime de tráfico de drogas. Também teve passagem por tráfico de drogas quando era adolescente. Reside em Jacareí com a sua genitora. Trabalha fazendo esfiha em uma pizzaria.

A testemunha MATHEUS DOS SANTOS PAULINO, policial militar, relatou durante a fase policial que na data dos fatos realizava patrulhamento juntamente com seu colega de farda pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

1ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/n, Jacareí-SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501116-27.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501116-27.2021.8.26.0617

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2214707/2021 -

DISE- DEL.SEC.JACAREI, 19507207 - DISE- DEL.SEC.JACAREI, 50/21/502 - DISE-

DEL.SEC.JACAREI, 2214707 - DISE- DEL.SEC.JACAREI, 2214707/2021 - DISE-

DEL.SEC.JACAREI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS JOSE DE PAULA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Vistos.

1.LUCAS JOSÉ DE PAULA e FELIPE MACHADO DE JESUS, qualificados nos autos, foram presos em flagrante e denunciados pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, no dia 09 de agosto de 2021, por volta das 12h15, na Rodovia

Nilo Máximo, 1, zona rural, nesta cidade e Comarca de Santa Isabel, traziam consigo, para fornecimento de terceiros, duas pedras de cocaína, na forma de crack, contendo o peso líquido total de 99,78g (noventa e nove gramas e setenta e oito centigramas), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização legal, além de uma balança de precisão, um aparelho celular e a quantia de R\$ 40,00.

A denúncia foi oferecida em 31 de agosto de 2021 (fls. 136/138).

Os réus foram devidamente citados e apresentaram defesa prévia (Réu Felipe fls. 199/200 e réu Lucas fls. 210/213).

A denúncia foi recebida em 04 de novembro de 2021 (fls. 217/221).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas. Ao final os réus foram interrogados.

Em debates, o Dr. Promotor de Justiça, após análise da prova produzida, postulou a condenação dos réus nos termos da Denúncia, por entender que restou demonstrada a acusação nesta narrada.

A Douta Defesa do réu Felipe alegou, preliminarmente, nulidade das provas produzidas decorrente da abordagem realizada pela polícia militar, com violação ao artigo 244, do CPP. Subsidiariamente requereu a absolvição por falta de provas ou a desclassificação para o tipo penal previsto no artigo 28, da Lei de Drogas. Ainda de forma subsidiária, no caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, e o regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, facultando-se o apelo em liberdade.

Na mesma toada foi a manifestação final da Douta Defesa do corréu Lucas, que apontou nulidade na prova decorrente da abordagem policial e no mérito, superada a preliminar, também postulou a desclassificação da conduta inicial para a prevista no artigo 28, da Lei de Drogas, requerendo, por fim, a fixação da pena no mínimo legal e o regime inicial diverso do fechado, facultando-se o apelo em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e decido.

2.A ação penal é improcedente.

Com efeito, a materialidade do delito está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 08/10), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11/12), Laudo de Constatação Provisória de Substância Entorpecente (fls. 43/45), bem como pelo Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 126/128, que constatou tratar-se, efetivamente, de substâncias entorpecentes.

O réu FELIPE MACHADO DE JESUS, interrogado em solo policial, declarou que na data dos fatos encontrava-se na Padaria Pitoresco, em seu local de trabalho, quando foi abordado por policiais militares no interior do referido estabelecimento, revistado e conduzido para fora. Nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Havia outro indivíduo no interior de uma viatura policial, que soube posteriormente tratar-se de Lucas, que não conhecia. Negou ter vendido a pedra de crack à Lucas ou que estivesse na posse da pedra da referida droga apresentada pelos policiais apenas na Delegacia de Polícia. Aduziu, por fim, que 15 dias antes os mesmos policiais prenderam em flagrante seu primo Willian, ocasião em que foi testemunha dos fatos e desde então passou a ser perseguido pelos referidos milicianos, os quais inclusive o abordaram naquele mesmo dia durante a manhã. Em juízo, ao ser interrogado, o réu negou novamente a imputação. No dia dos fatos estava trabalhando no momento quando foi abordado pelos policiais no momento em que estava varrendo a rua na porta da

padaria. Não portava absolutamente nada de ilícito. Depois de meia hora os policiais voltaram com outro indivíduo já detido na viatura policial no porta-malas e foi novamente abordado juntamente com seu patrão. Todas as drogas foram encontradas com o menino (corrêu Lucas). Uma semana antes dos fatos o seu primo foi detido e acabou sendo testemunha dele no Distrito Policial. Acredita que está sendo prejudicado por conta disso. A balança apresentada pertencia à padaria onde trabalhava (atendia clientes e fazia pão). Nunca tinha visto o acusado Lucas na sua vida antes dos fatos. O seu patrão também foi revistado. Os policiais queriam que informasse onde haveria mais drogas, pois caso contrário eles iriam "jogar" metade das drogas nas suas costas. Os policiais que participaram da diligência passavam diariamente no seu estabelecimento após a prisão do seu primo. Atualmente tem 27 anos de idade e reside nesta cidade de Jacareí. Já foi preso e processado por tráfico de drogas no ano de 2014. Não tem filho. réu tornou-se revel, pois não compareceu à audiência na qual seria interrogado.

O corrêu LUCAS JOSÉ DE PAULA, interrogado durante a fase investigatória, afirmou que as duas pedras de crack apresentadas pelos policiais eram de sua propriedade. Não conhece o corrêu Felipe. Em juízo, ao ser interrogado, o réu voltou a negar o crime, apresentando basicamente a mesma versão. As drogas encontradas em seu poder eram destinadas ao seu próprio consumo. Estava na posse de uma pedra pesando 50gramas aproximadamente. Ao ser questionado sobre o conteúdo do interrogatório extrajudicial, onde estava acompanhado do seu advogado Dr. Alan Lutfi, o acusado permaneceu em silêncio e se recusou a responder aos questionamentos. Atualmente tem 24 anos de idade. Já foi preso e processado no ano de 2016 por crime de tráfico de drogas. Também teve passagem por tráfico de drogas quando era adolescente. Reside em Jacareí com a sua genitora. Trabalha fazendo esfiha em uma pizzaria.

A testemunha MATHEUS DOS SANTOS PAULINO, policial militar, relatou durante a fase policial que na data dos fatos realizava patrulhamento juntamente com seu colega de farda pela Rodovia Nilo Máximo, próximo à entrada do Bairro Cidade Salvador, ocasião em que avistaram um veículo Onix, placas FLO 9037, com dois ocupantes. O indivíduo que estava no banco traseiro demonstrou nervosismo ao visualizar a viatura oficial. Resolveram, então, dar ordem de parada ao veículo e constataram que o condutor prestava serviço de motorista de aplicativo. Durante a busca pessoal encontraram em poder do passageiro Lucas José de Paula, no bolso, uma pedra de crack a granel pesando aproximadamente 50 gramas, suficiente para confeccionar cerca de 100 unidades, um aparelho celular e a quantia de R\$ 20,00 reais. Ao ser indagado o implicado admitiu ter adquirido a droga minutos antes na Rua Expedicionário Pedro Paulo Moreira, junto a pessoa de Felipe. Por conta dos fatos, seguiram até referido endereço, oportunidade em que Lucas apontou o implicado Felipe Machado de Jesus como sendo a pessoa que lhe forneceu a droga, motivando a imediata abordagem do mesmo em frente à padaria, seu local de trabalho. Felipe estava na posse de uma pedra de crack a granel pesando aproximadamente 50 gramas e a quantia de R\$ 20,00 reais. Por fim, realizaram buscas no interior do estabelecimento comercial e na residência vizinha após autorização do proprietário, no entanto nada de ilícito fora constatado. Os réus foram presos em flagrante e conduzidos ao Distrito Policial. Em juízo apresentou basicamente o mesmo relato, confirmando a diligência que culminou com a prisão do acusado. Não se recorda de ter abordado o acusado Felipe no período da manhã na data dos fatos. Ao contrário do que afirmou o seu colega, policial Judney, que participou da diligência Mateus aduziu que o acusado Felipe estava sozinho quando foi abordado e tentou empreender breve fuga, virando de costas e ingressando no estabelecimento. Não fez menção ao fato de o dono da padaria estar conversando com Felipe naquele momento, afirmando, apenas, que haveria outro indivíduo nas proximidades. Esse indivíduo que estava próximo e que teria presenciado a abordagem foi qualificado no relatório, mas não foi conduzido ao Distrito Policial. Para justificar a abordagem inicial do veículo UBER o policial Mateus aduziu que o acusado Lucas teria se agachado dentro do carro ao visualizar a presença da polícia (o colega Judney afirmou que Lucas apenas olhou para baixo). O veículo Uber não tem insulfilm e era possível ter a plena visão da parte interna dos ocupantes.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar JUDNEY ALVES, que também participou da diligência que culminou com as prisões dos acusados. Mas os relatos dos policiais possuem algumas contradições. Não tem como informar quantas porções de drogas podem ser confeccionadas com a pedra apreendida em poder do acusado Felipe. Para fundamentar a busca pessoal aduziu que Lucas teria se agachado dentro do carro ao visualizar a presença da polícia. Judney afirmou que o acusado estava na porta da padaria conversando com o patrão e não esboçou fuga, ao contrário do que informou o seu colega de farda e condutor Matheus.

A testemunha de defesa ISABELA CAROLINI ROSA SILVA, declarou ser amiga do acusado Lucas. Por volta das 09h00 da manhã o acusado, que trabalha como pintor, passou na sua casa dizendo que iria adquirir droga para o seu próprio consumo. Ele estava "bastante viciado" e consumia "crack" constantemente. Sabe que o réu adquiriria a droga de uma vez para poder passar o mês e não ter que retornar à biqueira. Não conhece o corréu Felipe. m juízo

Pois bem.

De rigor o acolhimento da preliminar arguida pela Defensoria Pública em sua manifestação final, havendo, neste caso, manifesta atuação ilícita da polícia militar no ato da busca pessoal, violando o artigo 244, do Código de Processo Penal, e contaminando todas as provas produzidas desde então.

O Superior Tribunal de Justiça, interpretando o artigo 244, do Código de Processo Penal, pacificou o entendimento no sentido de que não havendo fundada suspeita que justifique a abordagem policial a conduta dos milicianos será ilegal, maculando toda a prova produzida.

Nesse sentido o HC nº 158.580, pela Sexta Turma, de Relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, que bem expôs em seu voto: "para a realização de busca pessoal – conhecida popularmente como 'baculejo', 'enquadro' ou 'geral' –, é necessário que a fundada suspeita a que se refere o artigo 244 do Código de Processo Penal seja descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência para a diligência". Ainda: "o fato de terem sido encontradas drogas durante a revista não convalida a ilegalidade prévia [...] a violação das regras legais para a busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida".

Outros acórdãos foram proferidos pelo Tribunal Cidadão no mesmo sentido e pacificaram o tema. Confira-se a propósito o HC 163.49, relatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que ainda apontou que mera denúncia anônima não justificaria a abordagem pessoal de um indivíduo que transitava em via pública de bicicleta.

No caso em tela, o acusado Lucas se encontrava sentado dentro de um veículo conduzido por um motorista parceiro da empresa UBER, que possui os vidros totalmente transparente, e teria abaixado a cabeça (segundo o policial Judney), ou se agachado (segundo o policial Mateus) quando foi encarado por policiais militares que realizavam patrulhamento.

Não havia fundada suspeita. Nenhum ato de traficância foi constatado. Não houve fuga pelo motorista do veículo e não havia denúncias anônimas. Como bem apontou o Douto Defensor Público não se constata justa causa para a abordagem

Esta circunstância, na esteira da sólida jurisprudência do STJ, não pode ensejar a abordagem do indivíduo, violando o que estabelece o artigo 244, do Código de Processo Penal.

Declaro nula, portanto, a busca pessoal realizada e as provas dela decorrentes.

Por outro lado, além das contradições acima apontadas nos depoimentos dos policiais militares, mesmo que não se reconhecesse a prova ilícita decorrente da busca pessoal realizada, observo que nenhum ato de venda de drogas foi presenciado pelos milicianos e nenhuma investigação previa foi desenvolvida.

Aliás, não havia sequer denúncia anônima apontando a traficância pelos acusados em comparsaria.

Outro ponto que chama a atenção deste julgador é o fato de que o patrão do acusado, que o acompanhava no momento da abordagem policial, sequer foi qualificado e conduzido ao Distrito Policial para prestar depoimento. Aqui é importante lembrar que o policial Matheus disse que o réu Felipe estava sozinho quando foi abordado defronte à padaria, e tentou empreender fuga, enquanto o seu parceiro e colega de farda Judney, que estava presente na mesma cena, afirmou que Felipe estaria conversando com outro indivíduo quando foi abordado, o mesmo que sequer foi conduzido ao Distrito Policial como testemunha, lamentavelmente. E também não fez menção à qualquer tentativa de fuga por parte de Felipe.

Além disso, há notícia nos autos de que o acusado Felipe ter figurado como testemunha de defesa em favor do seu primo que foi preso em flagrante uma semana antes dos fatos pelos mesmos policiais. O Policial Matheus sequer soube explicar se conhecia ou não o acusado Felipe quando este foi conduzido preso em flagrante. Neste ponto Felipe acusa os policiais que atuaram na ocorrência de perseguição e afirma ter sido abordado naquele mesmo dia pela manhã.

A apreensão da balança de precisão em nada altera o contexto fático e jurídico, posto que o acusado Felipe trabalhava em uma padaria e o objeto poderia ser perfeitamente utilizado naquele estabelecimento para pesagem de alimentos (frios) ou mesmo para preparo de pães e outros produtos. Nenhum resquício de droga foi encontrado na balança. E não é crível que o réu utilizaria uma balança em plena atividade no comércio onde trabalhava para pesar substâncias entorpecentes.

Além de não qualificar e apresentar como testemunha o dono da padaria, que presenciou toda a abordagem de Felipe, os mesmos milicianos também não conduziram o motorista de UBER, onde o acusado Lucas estava e foi inicialmente abordado, na condição de testemunha ao Distrito Policial, o que também é inadmissível para uma diligência deste porte.

Portanto, havendo dúvida razoável quanto ao crime de tráfico de drogas imputado aos réus, mormente diante ilegalidade da busca pessoal inicialmente realizada, dela decorrendo outras diligências que culminaram com a apreensão de drogas, é de rigor a absolvição dos acusados com base no clássico princípio do *in dubio pro reo*.

Em matéria criminal: “Não estando suficientemente demonstradas as provas da materialidade, autoria e o elemento subjetivo, simples indícios do ilícito não são suficientes para um Juízo de condenação” (TRF, 2ª Região – Ap. – Rel. Alberto Nogueira – RT 725/675).

No mesmo sentido: “É impossível fundar solução condenatória em prova que não conduz a certeza, não bastando a probabilidade, sobre o juízo da existência de certo fato ou mesmo a convicção íntima, sem o concurso de dados objetivos de justificação” (Tacrím – SP – Ap. Rel. Passos de Freitas – RJD 20/176).

Em Direito Penal a prova cabe a quem acusa e não pode ser dirigida a quem se diz inocente. Brilhante a lição de Nicola Framarino Dei Malatesta: “O ordinário do homem é a inocência, por isso ela se presume e é ao acusador que cabe a obrigação da prova no juízo penal.... Mas quando em geral se trata do ônus da prova em juízo

penal, fala-se em obrigação de produzi-la como sustentação de uma dada afirmação. Ora, aberto o juízo penal, aí deverá sempre existir a imputação de crime e, por isso, um acusador e um acusado, bem como uma afirmação acusadora e uma eventual afirmação defensiva. A estas duas asserções se refere o problema do ônus da prova, visando estabelecer qual das duas deve provar-se primeiro. Neste caso, não se poderá nunca dizer que a obrigação da prova incumbe ao juiz que deve pronunciar; o juiz, como tal, não afirma nada, deve julgar entre as várias afirmações e provas; é obrigação sua, como juiz, no momento da produção das provas, limitar-se a colher todas as provas que possam conduzir à verdade judicial, fim supremo de todo processo. Não é, portanto, errôneo, o falar de prova relativamente ao acusado e acusador. Voltando ao que dizíamos e concluindo, a inocência se presume. Por isso, no juízo penal, a obrigação da prova cabe à acusação" (A Lógica das Provas em Matéria Criminal, tradução Paolo Capitanio, ed. Bookseller, 1996, págs. 134 e 136).

4. Posto e pelo que mais consta dos autos JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para o fim de ABSOLVER os réus LUCAS JOSÉ DE PAULA e FELIPE MACHADO DE JESUS do crime contra eles imputado na denúncia, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Com o trânsito em julgado, mantida esta sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Jacarei, 16 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA